

1500773-93.2021.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTINA ESCHER

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... o réu. O local era conhecido pelo tráfico. Não estava de campana, estava fazendo verificação. Entraram naquela rua que sabem que tem tráfico. Josué estava subindo a rua, em direção à esquina, indo em direção ao usuário. O terreno fica a uns 20 m aproximadamente da esquina, bem próximo. Enquanto o réu subia a rua, acompanharam com a viatura, foi o tempo de entregar a droga. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

2ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500773-93.2021.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500773-93.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082730/2021 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU,

12/21/219 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 2082730 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 2082730 -

DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSUÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

JOSUÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"..no dia 24 de março de 2021, por volta das 15:00 horas, na Rua José Maria Godoi, esquina com a Rua 16, Jardim Monte Mor, nesta cidade e comarca, JOSUÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 10, foi surpreendido vendendo e mantendo em depósito

drogas para distribuição ao consumo de terceiras pessoas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conforme o apurado, o denunciado exercia o tráfico de drogas. No dia dos fatos, ele foi surpreendido vendendo 02 (dois) papélotes de "crack" e mantendo em depósito outros 13 (treze) papélotes do mesmo entorpecente, todos com peso líquido de 3,19 g. (três gramas e dezenove decigramas).

Com apoio de viatura descaracterizada, policiais civis realizavam observação pelas imediações, em pontos conhecidos como locais de venda de drogas.

Durante a observação, os policiais ingressaram em uma das ruas e lá observaram o momento em que o denunciado entregava alguma coisa para Cleiton Gimenez. Os policiais se aproximaram e abordaram ambos.

Naquele momento, Cleiton dispensou dois papélotes de "crack" que havia acabado de receber das mãos do denunciado.

Em busca pessoal, os policiais encontraram com o denunciado a quantia de R\$ 8,00 (oito reais).

Indagado, Cleiton afirmou que havia acabado de comprar as drogas do denunciado, pois era usuário daquele entorpecente.

Por seu turno, o denunciado confessou que havia realizado a venda do entorpecente para a testemunha, mas assegurou que não possuía qualquer outro entorpecente.

Contudo, os policiais, momentos antes da abordagem, visualizaram o denunciado caminhando pelo local, como se tivesse saído de uma construção ali existente.

Os policiais foram até o local e lá encontraram mais 13 (treze) papélotes de "crack", embalados de forma idêntica àqueles que foram encontrados com Cleiton.

Sobreveio a prisão em flagrante.

O laudo de constatação de fls. 14/19 indicou que as substâncias apreendidas eram "crack".

O rito procedimental da Lei 11.343/06 foi convertido em ordinário, a denúncia foi recebida (fl. 92/93), o réu foi citado (fls. 110) e apresentou resposta à acusação (fls. 111/121). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 127/128) e designada audiência de instrução. Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Nos debates escritos, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (fls. 265/271).

A defesa do réu requereu aplicação da atenuante da menoridade e da confissão, aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, aplicação da atenuante da menoridade, aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei 11.340/06, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, aplicação de regime aberto e direito de apelar em liberdade (fls. 274/285).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 04), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 80/82) e pela prova oral colhida.

A autoria está, igualmente, caracterizada.

A testemunha de acusação João de Oliveira Fernandes, policial civil, disse que estava em patrulhamento com Rafael no bairro Monte Mor, que é um local já conhecido pelo tráfico. Quando entrou na rua, avistou Josué subindo em direção a uma esquina.

O avistou claramente entregando, na esquina, alguma coisa e recebendo outra de volta. Estava bem próximo e já abordaram Josué. Cleiton, que era o usuário, estava com a droga na mão, que jogou no chão. Abordou Cleiton e Rafael abordou Josué.

Cleiton admitiu que tinha acabado de comprar droga e Josué admitiu que tinha vendido. Eles se conheciam, faziam sempre essas vendas. Em frente ao local da abordagem, há um terreno com uma construção. Como é normal esconderem drogas em

terreno, ingressou ali e encontrou outros três pacotes que Josué negou ser dele. Josué confessou que traficava e que ali não era o seu local mas estava vendendo drogas. Cleiton ainda disse que já tinha comprado dele várias vezes. Não conhecia o réu. O local era conhecido pelo tráfico. Não estava de campana, estava fazendo verificação. Entraram naquela rua que sabem que tem tráfico. Josué estava subindo a rua, em direção à esquina, indo em direção ao usuário. O terreno fica a uns 20 m aproximadamente da esquina, bem próximo. Enquanto o réu subia a rua, acompanharam com a viatura, foi o tempo de entregar a droga. Ele não percebeu a viatura, tanto que Cleiton jogou a droga no chão quando estavam frente a eles. Josué estava com oito reais. Na delegacia, ele disse que esse valor seria de uma compra que fez e Cleiton lhe estava devendo e foi até lá para pagar a diferença. Josué não tinha o dinheiro da venda da droga, apenas portava oito reais no momento da abordagem, que era referente a uma compra anterior que Cleiton tinha feito. Cleiton não esclareceu se tinha pagado pelas pedras. Não sabe dizer se Josué tinha sido preso anteriormente. Ele comentou que tinha problemas de saúde, que tomava remédios. Um familiar de Josué chegou ao local e confirmou que ele tinha uns problemas e tomava remédios.

A testemunha de acusação Rafael Coiado Geisenhoff, policial civil, disse que estava junto com seu colega fazendo patrulhamento no local dos fatos, observando a movimentação do lugar que é conhecido como ponto de tráfico. Passando com a viatura na rua em que o réu se encontrava, o avistaram defronte a um terreno, uma construção. Nesse momento passou a caminhar em direção à esquina da rua, em direção a uma pessoa, um usuário. Eles se encontraram na esquina, momento em que um entregou uma coisa para o outro. Em seguida, como o estavam acompanhando com o carro, o abordaram. Abordaram Cleiton, que de imediato, já jogou duas pedras de crack no chão. Abordou o réu e seu colega abordou Cleiton. Com o réu foram encontrados oito reais. No momento, o usuário admitiu que teria ido ali para comprar drogas do réu. Em seguida, o colega foi até o terreno onde ele estava e localizou mais algumas pedras de crack, aproximadamente treze pedras. Essas pedras estavam acondicionadas de maneira semelhante no tamanho e embalagem das que Cleiton dispensou. Não conhecia o réu. Josué e Cleiton confessaram no momento da abordagem. Avistou o usuário entregando dinheiro e o réu entregou, provavelmente, as pedras. Viram essa troca. O usuário admitiu que já tinha ido ali outras vezes comprar drogas. Chegou na rua pela mesma via que Josué caminhava e o avistou caminhando em direção ao usuário. Houve uma troca entre eles, um entregando ao outro uma coisa, ao mesmo tempo. Com o réu foi encontrado apenas a quantia de oito reais. Num primeiro momento, o usuário não falou muito, apenas dizendo que tinha ido comprar droga e o réu confessou que estava vendendo. Na delegacia, mudaram a história, dizendo que tinha adquirido a droga em momento anterior, não ficou bem esclarecido. Do terreno até a esquina havia duas residências. Estava a vinte metros da esquina. Verificou que o réu não tinha nenhuma passagem. Não lembra do réu ter se manifestado sobre arrependimento do crime. Recorda que um familiar ou amigo disse que ele tinha algum problema, que ele desmaiava e que ele tomava remédios para isso.

Por fim, a testemunha de defesa Dalva Gregório disse que conhece Josué desde pequeno, de Vitoriana. Ele sempre foi um bom menino, ele sofre de "ataques", faz uso de medicação para essa doença. Ele estudava. Atualmente, ele reside com o avô dele, em Botucatu. Soube que ele foi preso no início do ano. Ficou surpresa porque ele sempre foi um menino bom. Ele apresenta bom comportamento.

O réu, em sede policial, confessou os fatos. Disse que "É verdade que vendeu os papelotes de crack/ dois, ao usuário. Mas foi antes da abordagem. É que ele tinha voltado pra entregar o restante do dinheiro, 8 reais, que ficou devendo. Não tinha mais droga. Os papelotes de crack que os policiais encontraram numa construção abandonada próximo da abordagem não pertenciam ao interrogado. Existem outras pessoas que atuam no tráfico naquela localidade e provavelmente os papelotes sejam dessas outras pessoas. O interrogado tinha pego poucos papelotes para a venda, que já tinham acabado. Não quer falar o nome dos eventuais comparsas. Contou que possui crises de epilepsia e que toma medicamentos controlados diariamente. Faz tratamento

na UNESP de Botucatu. Nunca foi preso. Pede uma segunda chance, dizendo que jamais fará isso novamente." Em juízo, o réu disse que tem 20 anos. Não tem outros processos. Certa vez emprestou R\$ 8,00 para o senhor Cleiton em um bar. Ele comprou cigarro e uma garrafa de bebida. Passadas uma ou duas semanas, ele apareceu lá e estava saindo para ir no mercado. Ele o reconheceu, o cumprimentou e entregou os R\$ 8,00 que devia. Entrou novamente na casa, pegou uma máscara e os R\$ 8,00. Quando estava saindo foi abordado na frente do portão da sua casa. As drogas estavam com Cleiton, que estava pulando a cerca, da rua para o pasto. Consigo tinha apenas R\$ 8,00. Não é viciado em entorpecentes, apenas cigarro. Não sabe se Cleiton vendia entorpecentes. Mora nos fundos do quintal do seu avô e é ele quem o ajuda já que não trabalha e está com processo para conseguir o benefício LOAS. Essa versão é a mesma que deu quando foi abordado. A droga encontrada não era sua. Toma remédio para convulsão.

Pois bem. O réu, em juízo, inovou, trazendo versão diversa da apresentada em sede policial, restando evidente que o réu mentiu para se livrar do decreto condenatório.

De acordo com Júlio Fabrini Mirabete (Processo Penal, 4ª Edição, São Paulo, Ed. Atlas, pág. 285) "a confissão extrajudicial, que não se reveste da garantia do Juízo, é insuficiente, por si só, para embasar uma condenação, mas deve ser admitida como prova para condenação quando amparada em outros elementos colhidos nos autos"

Assim, o art. 155 do Código de Processo Penal veda a utilização dos elementos informativos como fundamento exclusivo da decisão, mas nada impede, na atual configuração sistemática do Processo Penal, que sejam utilizados para reforçar a prova produzida em juízo, como o foram neste caso.

Neste sentido:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA SENTENÇA. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas. 2. Na espécie, o édito condenatório lastreado em declarações colhidas de testemunhas na fase inquisitorial, bem como em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não resulta em ilegalidade. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 117192, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 16-09-2013 PUBLIC 17-09-2013).

No tocante à finalidade com que o réu trazia a substância entorpecente, não há qualquer dúvida de que a sua intenção era a de entregá-la ao consumo de terceiros, em razão do local em que o réu foi encontrado (ponto de tráfico), das drogas encontradas, da confissão informal aos policiais, que, por si só, já é suficiente para a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo incompatível com o uso momentâneo.

Há que se ressaltar a validade jurídica e a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares:

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (Habeas Corpus nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97, p. 12.189).

No mais, o réu foi flagrado pelos policiais entregando algo a um indivíduo (Cleiton), que assumiu informalmente ser usuário e que havia comprado drogas do réu, porém as dispensou no momento da abordagem, sendo que com o réu foi encontrada

uma quantia em dinheiro (R\$ 8,00). Também foi localizado em um terreno próximo, mais treze porções de drogas iguais as encontradas com o usuário Cleiton, denotando ilicitude em sua conduta (fls. 14/19 e fls. 53/58).

Frise-se que o local dos fatos era conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.

Além disso, as drogas dispensadas pelo usuário e as demais encontradas em um terreno próximo estavam acondicionadas da forma como as substâncias entorpecentes costumam ser embaladas para o comércio, conforme o laudo pericial.

Nesse sentido:

“Tóxico – Tráfico – Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado – Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio – Desclassificação para uso inadmissível.” (TJSP – AC 234.718-3 – Rel. Walter Guilherme – j. 17.02.1998 – JTJ 208/273).

Por fim, o depoimento da testemunha de defesa, Dalva Gregório, nada acrescentou que pudesse favorecer o réu.

Demonstrada, então, a ocorrência do crime de tráfico de drogas e comprovada a responsabilidade criminal por tal delito, a procedência da denúncia é a medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena

Analisando as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, fixo a pena no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Em segunda fase, deixo de atenuar a pena em razão da menoridade, porque já no piso.

O artigo 33, parágrafo 4º, da lei agora em vigor, dispõe que: “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Deve ser observado que vários doutrinadores tem sustentado a inconstitucionalidade de referido dispositivo legal, dentre os quais destaco Fernando Capez (in Curso de Direito Penal – Legislação penal especial, 14ª ed., 2019, fls. 765/767) que a defende baseando-se no fato de que essa previsão de redução de pena à agentes primários e portadores de bons antecedentes, que não integrem organizações criminosas, criou um privilégio específico para os traficantes, do qual não dispõe nenhum autor ou participe de outro crime.

Os bons antecedentes fazem parte das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, portanto, não podem reduzir a pena aquém do mínimo previsto. Também a primariedade, não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 231). Se promovidos a condição de causa especial de diminuição de pena iriam beneficiar os traficantes de modo muito mais eficaz do que a qualquer outro infrator, até mesmo em crimes de menor potencial ofensivo. Tal possibilidade coloca em risco o sistema principiológico que norteia a aplicação das penas no Código Penal, violando em especial o princípio da proporcionalidade, acarretando ainda grave instabilidade à ordem social e à segurança da coletividade.

Evidencia-se, do texto da norma referida, que o legislador quis favorecer o autor eventual de tráfico de “pequena” monta, e não aquele que se dedica permanentemente a tal atividade criminosa.

Ao dispor que as penas “poderão” ser reduzidas, evidentemente referindo-se às penas previstas no “caput” daquele dispositivo, a norma em questão não impõe a redução da pena, em todos os casos, aleatoriamente, o que ofenderia à Constituição Federal. A norma do parágrafo 4º em questão prevê situações que, se constatadas, certamente inviabilizarão, por completo, o benefício.

Devem ser analisadas tais circunstâncias em cada caso.

Assim, caso seja o réu reincidente, tenha maus antecedentes, dedique-se a

atividades criminosas ou integre organização criminosa, em hipótese alguma fará jus à redução da sua pena.

Mas, sendo primário, tendo bons antecedentes, e não se dedicando a atividades criminosas, nem sendo integrante de organização criminosa, poderá ou não fazer jus à redução da sua pena de um sexto a dois terços, conforme as circunstâncias do caso concreto. Aqui, entendo que o julgador deve socorrer-se, ainda, dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal e das peculiaridades do caso concreto, quer para verificar a viabilidade da aplicação do redutor da pena, quer para aplicar a redução mais adequada à hipótese.

Assim, é imprescindível, para a perfeita individualização das penas, e para evitar-se a eterna banalização das penas mínimas, que certamente não corresponde ao intuito do legislador nem aos anseios sociais, menos ainda à justa aplicação da lei ao caso concreto, analisar criteriosamente, além das condições previstas no parágrafo 4º do artigo 33, também as circunstâncias e consequências do crime, a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente, e os motivos que o levaram à prática da infração.

Com efeito, assim registrou o preclaro Desembargador Luiz Antônio Cardoso, da 3ª Câmara de Direito Criminal do E. TJSP, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 0036916-89.2011.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. 30.07.2013):

"Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder.x

Nesse sentido é o posicionamento do E.TJ/SP, no seguinte julgado:

"Lei de Tóxicos (nº 11.343/06). Tráfico. Crime caracterizado, integralmente.

Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento impassível de abrandamento. Fixação da pena base no mínimo legal, diante da aplicação dos critérios explicitados em determinação do C. S.T.J. Inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Regime inicial fechado -único possível. Inviabilidade de substituição da corporal por penas alternativas. Apelo improvido." (Apelação nº 0022448-60.2013.8.26.0050, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, j. 29/01/2019).

No caso dos autos, muito embora, o acusado seja primário, não há uma hipótese de extrema excepcionalidade a autorizar a redução, diante do contexto em que ele foi abordado, qual seja, em local conhecido como ponto de tráfico, o encontro de razoável quantidade de droga (15 porções de cocaína). Enfim, indicativos que demonstram que o réu estava a se dedicar a atividade criminosa da traficância, afastando a ideia de que ele era traficante ocasional e que incorreu no tráfico em uma única vez. Dessa forma, na terceira fase, justifico a ausência de aplicação da redução de pena nos moldes do artigo art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista a natureza hedionda do delito de tráfico de entorpecente, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

Sobre a pertinência da fixação de referido regime de cumprimento de pena, trago o seguinte precedente:

"Por fim, mantenho o regime inicial fechado para início do desconto da corporal, sendo o único compatível com o delito, dada a determinação legal em se tratando de crime hediondo (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90). Cumpre observar que o ilícito do qual ora se trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado permitirá aos réus uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, AP 0002479-41.2010, Rel. Edison

Brandão, j. 02/07/2013).

Como se sabe, a finalidade da lei é proteger a saúde pública, evitando-se o dano que o uso de drogas causa à saúde e a única forma de se coibir tal prática, com sucesso, é através do combate ao narcotráfico e da não permissão de que aqueles que se veem acusados e até condenados de tais práticas sejam, desde logo, reintegrados ao convívio social, sem que percebam a gravidade de suas ações.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu JOSUÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a aplicação do "sursis", em razão de não estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, em favor da União, para conversão em renda do FUNAD. Transitada em julgado, requirite-se a transferência.

O réu, por estar em liberdade (fls. 194), poderá recorrer nesta condição.

Honorários proporcionais

Custas na forma da Lei.

Botucatu, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA